

1506275-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... em via pública, em ponto de tráfico de drogas, submetendo-se ao risco de ser abordado e preso, como de fato foi. Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar demonstrada a autoria. Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Rua 5 - 1º Piso - Salas 1-385 e 1-386, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2127-9038, São Paulo-SP - E-mail: sp19cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1506275-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070875/2022 - 73º D.P. JACANA, 23598459 - 73º D.P.

JACANA, 2070875 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARNALDO ALVES DOS SANTOS MANOEL

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

28/07/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 28 de julho de 2022, às 13h30, conforme determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente realizada de forma mista, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado(a) à sala virtual, foi aberta a audiência com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão: do(a) representante do Ministério Público Dr(a). Paulo Henrique Castex; do acusado Arnaldo Alves dos Santos Manoel e de seu advogado Antonio Roberto Achcar (OAB 39288/SP); Presentes as testemunhas

Emanuel Pegorari Ramos e Lucas Rodrigo Moreira da Silva. Aberta a teleaudiência, pela Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas, ouvidas e qualificadas nos autos, considerando o Provimento CSM nº 2.651/22. Procedeu-se ao interrogatório do acusado, em mídia digital. Sem requerimentos das partes. A seguir, pelo(a) MM Juiz(a) foi deliberado o seguinte: "Declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates". Pelo Ministério Público foi dito: alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) advogado(a) do acusado foi dito: alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi dito: "Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de ARNALDO ALVES DOS SANTOS MANOEL o, na qual lhe é imputada a prática de infração penal (art. 33 da Lei n. 11.343/06). Narra-se na denúncia: "no dia 14 de março de 2022, por volta de 10h30, na Rua Alvorada D'Oeste, 73, Rua Nossa Senhora Aparecida do Nilo, Vila Nova Carolina, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, ARNALDO ALVES DOS SANTOS MANOEL, qualificado a fls. 13 e 19, trouxe consigo para fins de tráfico, 87 (oitenta e sete) porções de cocaína em formato de pedra de crack, com massa líquida de 28,9g (vinte e oito gramas e nove decigramas) e 37 porções de cocaína, com massa líquida de 15g (quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.17), laudo de constatação nº 79773/2022 (fls. 05/08), e laudo químico-toxicológico a ser juntado." Promovida a notificação, foi apresentada defesa prévia. A denúncia foi recebida. Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório. Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir. Trata-se de ação penal pública na qual veiculada imputação da prática de infração penal, à luz do art. 33 da Lei n. 11.343/06). Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito. A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial de constatação e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 134/136), que apontam se tratar de drogas descritas nas listas F1 e F2 da Portaria n. 344/1998-SVS/MS (complemento das normas penais em branco constantes da Lei n. 11.343/06, por força do art. 66 do referido diploma legal), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo. Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos. A testemunha Lucas relatou que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento de rotina; que o local já era conhecido como ponto de tráfico e como as ruas são estreitas, pararam a viatura antes e desembarcaram a pé; que seu parceiro foi na frente e antes de ultrapassar essa rua visualizou o Arnaldo sentado com uma bolsinha rosa mexendo nas drogas e em volta dele havia 2 pessoas de bicicleta e outra a pé; que ele tentou jogar a bolsinha, mas pegou a bolsinha e deram voz de prisão; que ele confessou que a droga era dele e ele estava no tráfico; que o indivíduo a pé estava a pé, mas conseguiu detê-lo e o delegado o dispensou por não ter nada de ilícito; que Arnaldo estava sentado em uma cadeira ou sofá de cabeça baixa mexendo nas drogas, tanto que foi o último a visualizar, os de bicicleta correram; que ele admitiu que a droga dele e estava no tráfico; que ele também tinha dinheiro, salvo engano R\$ 65,00 em espécie; que não presenciou o depoimento do réu perante a autoridade policial; que quem pegou a droga foi o outro policial; que desembarcaram da viatura antes de ultrapassar a rua; que não se lembra se era uma bolsa ou estojo, mas era um objeto rosa; que a droga eram 37 porções de cocaína e 87 de crack. A testemunha Emanuel relatou que estavam em serviço quando adentraram local conhecido como ponto de tráfico; que viram que ninguém avisou quando a viatura chegou, não ouviram gritos; que então desembarcou da viatura e fez o fatiamento da viela para ver se havia alguém; que então viu o acusado sentado com um estojo em seu colo, mexendo no

estojo, e mais alguns indivíduos próximos; que foram andando perto da parede, um olheiro viu, avisou e saiu correndo, mas o acusado em questão não conseguiu correr, só jogou seu estojo; que seu parceiro pegou o estojo e outro indivíduo que tentou correr; que Arnaldo confessou que estava no tráfico e que as drogas eram dele; que ele não disse nada sobre o outro indivíduo; que não visualizou troca de objetos entre as pessoas que estavam lá; que o acusado estava mexendo no estojo; que os olheiros ficam nas esquinas e os outros ficam de bicicleta andando para ver se vem viatura; que esse rapaz de bicicleta o viu e avisou e saiu, mas não deu tempo de o acusado fugir; que não havia outras pessoas no local além desses de bicicleta e do outro que tentou fugir; que na ocasião da apreensão da droga não havia outras pessoas; que os dois fugiram e então ficaram o Uátilla e o Arnaldo; que não presenciou as declarações dele perante a autoridade policial; que seu parceiro pegou o estojo jogado à frente. O acusado relatou que estava sim com a droga, mas não vendendo, esperando alguém que iria guardar, e aí os policiais vieram e prenderam; que a droga não era para usar; que não sabe o que essa outra pessoa ia fazer com a droga; que não sabe o nome dessa pessoa; que a droga era cocaína e umas pedrinhas de crack; que essas pessoas não estavam fazendo nada, só moravam na comunidade. Diante das provas produzidas, quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011). Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo. Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021). No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012). No caso ora em apreço, verifica-se que o depoimento dos policiais é uníssono quanto às circunstâncias da abordagem e da apreensão. Quanto à hipótese alternativa ventilada, mesmo que acolhida fosse, não afastaria a autoria do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que a simples conduta de guardar a droga para terceiro, e não para consumo próprio, configura as elementares do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06. De todo modo, vale notar que a versão apresentada em autodefesa mostra-se de reduzida verossimilhança, tendo em vista que é pouco crível que pessoa cujo nome o acusado nem sequer sabe qual é teria pedido a ele para simplesmente guardar as drogas, com o que o acusado teria, graciosamente, concordado, sem contrapartida, aguardando em via pública, em ponto de tráfico de drogas, submetendo-se ao risco de ser abordado e preso, como de fato foi. Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar demonstrada a autoria. Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos

18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual

seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito), o que caracteriza o tráfico é a vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica. Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas. A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou suprallegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que o agente é imputável e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Assim, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal. Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI). Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes criminais demonstra a existência de uma condenação penal definitiva (cf. Súmula 444/STJ), cuja extinção de punibilidade ocorreu mais de cinco anos antes do fato-crime objeto deste feito (trata-se de fato ocorrido há 18 (dezoito) anos). Tal condenação não é apta a configurar reincidência em razão do sistema da temporariedade da reincidência (CP, art. 64). Quanto à possibilidade de aplicação de tal limitador temporal aos maus antecedentes, trata-se de questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 593.818, Tema 150), no qual se decidiu que tais condenações pretéritas podem ser desvaloradas como antecedentes negativos, salvo quando desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo (sistema da perpetuidade mitigado). Com efeito, cumpre reconhecer que o fato-crime pretérito praticado em passado demasiadamente remoto e sem nenhuma correlação com o crime objeto da condenação perde progressivamente a sua relevância e o seu vínculo em relação às condutas recentes do acusado e, assim, deixa de impactar no exame da reprovabilidade do fato atual. Diante de fato praticado há longo lapso de tempo sem vínculo com o fato-crime objeto da condenação, não se justificar o incremento da pena por tal razão, de modo automático e irrefletido. Assim, à luz do direito ao esquecimento e da formatação do direito penal em torno do fato (e não do autor), é razoável que, ultrapassado o lapso descrito no art. 64 do Código Penal, o órgão julgador proceda ao exame do efetivo incremento da reprovabilidade do fato-crime em exame em razão do mau antecedente remoto, à luz das características concretas do antecedente em questão e da sua relação com o fato-crime objeto da condenação. Uma vez firmadas tais premissas, verifica-se no caso que o antecedente em questão é isolado, relativo a fato-crime ocorrido há cerca de 18 (dezoito) anos do fato-crime ora em apuração. Tais características, portanto, desautorizam o incremento da pena-base em razão do antecedente registrado. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime. Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), serão valoradas apenas na terceira fase da dosimetria, para fixação do patamar da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a fim de evitar *bis in idem* indireto, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/AM, Plenário, j. 3.4.2014, Tema 712 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1887511/SP, Terceira

Seção, j. 09/06/2021). Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, no caso, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), mas a pena-base já foi fixada no mínimo legal, o que impede a atenuação desta fase, ante a impossibilidade de a pena provisória ser fixada em patamar inferior ao mínimo (Súmula 231/STJ). Na terceira fase, quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, configuradora do assim denominado "tráfico privilegiado", a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa. No caso, todos esses requisitos estão preenchidos, tendo em vista que a condenação isolada e antiga (fato de mais de 18 anos atrás), como fundamentado acima, não configura mau antecedente. Quanto às circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 ainda não analisadas (natureza e quantidade da droga), passa-se ao seu exame. Quanto à natureza da droga, verifica-se que no caso houve a apreensão de mais de uma espécie de substância ilícita, de modo a denotar maior reprovabilidade da conduta e justificar a valoração negativa de tal circunstância nesta fase da dosimetria. Sobre o tema, cf., por todos, STJ, HC 615.347/RS, DJe 15/12/2020. Ademais, quanto à cocaína/crack, trata-se de substância com elevado potencial nocivo à saúde e alto grau de dependência, o que deve ser valorado negativamente nesta fase da dosimetria. Quanto à quantidade de droga apreendida, não houve a apreensão de montante elevado de substância ilícita. Assim, fixa-se a fração de diminuição no patamar intermediário de 1/2 (um meio) e a fração de aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), a resultar na pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa. Assim, fixa-se a fração de diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e a fração de aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), a resultar na pena definitiva de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, mais 173 dias-multa. Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve ser atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, a primariedade do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime aberto, com base no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP. Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que eventual prisão preventiva não interfere na fixação do regime inicial, pois a pena originária já foi fixada no regime menos gravoso (aberto). Ante o preenchimento dos requisitos legais constantes do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, as quais ficam desde já individualizadas como (1) prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º), no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual deverá ser depositado em conta bancária que será informada posteriormente, em audiência admonitória, para destinação a entidade pública ou privada com destinação social, em atenção à Resolução n. 154/12-CNJ; e (2) prestação de serviços à comunidade, por tempo igual ao da condenação, em entidade a ser designada na fase de execução penal. Ante a substituição por pena restritiva de direitos, fica prejudicado o exame da suspensão condicional da pena (CP, art. 77, III). Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR o acusado ARNALDO ALVES DOS SANTOS MANOEL ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos na forma supra, mais 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06. Quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva (CPP, art. 387, § 1º), verifica-se que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, cuja revogação se impõe. Por tais razões, revoga-se a prisão preventiva determinada no curso do processo. Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente. Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas,

caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao dinheiro

apreendido, deve ser decretada a sua perda em favor do FUNAD (LAD, art. 63) na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ. Quanto à multa, prossiga-se na forma dos arts. 479 e 480 das NSCGJ. Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade, em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP)". Sem recurso do MP e sem recurso da defesa. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. Nada mais. Termo digitado e lavrado por mim, João Guilherme Berchiol Iwai.